

1504046-84.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504046-84.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504046-84.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2048387/2022 - 87º D.P. V. P. BARRETO, 23124694 - 87º D.P. V. P. BARRETO, 403/22/352 - 87º D.P. V. P. BARRETO, 2048387 - 87º D.P. V. P. BARRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO GRACIANO SILVA ARAÚJO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

FABRÍCIO GRACIANO SILVA ARAÚJO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. Porque, por volta de 14:00 horas, na Viela Vinte, altura do n.º 50, Pirituba, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 61 porções contendo Tetrahydrocannabinol, substância popularmente conhecida como "maconha", com peso líquido aproximado de 179,5g (cento e setenta e nove gramas e cinco decigramas), 11 (onze) porções contendo Tetrahydrocannabinol, na forma conhecida como "skunk", com peso líquido

aproximado de 0,71g (setenta um decigramas), 339 (trezentos e trinta e nove) porções contendo cocaína, com peso líquido aproximado de 213,24g (duzentos e treze gramas e vinte e quatro decigramas), 130 (cento e trinta) porções contendo cocaína, na forma conhecida como "crack", com peso líquido aproximado de 26,5g (vinte e seis gramas e cinco decigramas), e 06 (seis) recipientes contendo cloreto de metileno/diclorometano, substância popularmente conhecida como lança-perfume, com quantidade de 132ml (cento e trinta e dois mililitros), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante.

Notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006, fls. 122, o réu apresentou defesa preliminar, fls. 126/127.

A denúncia foi recebida, fls. 130/133, e o réu citado pessoalmente.

Na data de hoje, realizada a instrução, foram ouvidas três testemunhas de acusação e o réu interrogado ao final.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a procedência do pedido inicial, com a condenação do réu, recrudesimento da pena em razão da quantidade e variedade de entorpecente, inviabilidade da concessão do trafico privilegiado e perda dos valores apreendidos.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado em razão da fragilidade da prova produzida. Caso não acatada a tese, pena mínima, viabilidade do privilégio, regime diverso do fechado.

É o relatório.

Decido.

É procedente a ação penal porque, ao cabo da instrução criminal restou perfeitamente delineada a autoria e a materialidade do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 conforme mais adiante se verá.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls.20/ 23) e dos laudos de constatação provisória (fls. 52/57), bem como pelo laudo toxicológico definitivo de substancia entorpecente (fls.152/156), ambos com resultados positivos para CLORETO DE METILENO/DICLOROMETANO, COCAÍNA e TETRAHIDOCANNABINOL (THC).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes colhidos na fase inquisitiva.

Com efeito, o policial Eduardo reconheceu o acusado do recorrido. Estava em operação no combate de trafico. Constante mente recebe denuncia de moradores incomodados com a pratica. Foram ao local já conhecido inclusive de outros flagrantes de tráfico. O local é vizinho de um bar. Ficou aguardando na viatura e os demais que desceram. Viu o acusado antes da abordagem até porque passaram por ali algumas vezes para estruturarem a ação. O acusado estava no meio de outras pessoas e se encontrava com uma bolsa nas mãos, típico de trafico. Foi o policial Rodolfo quem fez a abordagem. A rua tem casas bem simples. Um outro local, já apos abordado, foi indicado pelo acusado onde estava o restante das drogas, em cima de uma caixa de água.

Policial Rodolfo reconheceu o acusado de uma ocorrência por trafico. O local é ponto conhecido de trafico de drogas, de difícil aceso, com muitos olheiros. O policial desceu com a motocicleta e resolveu abordá-lo porque ele estava com uma sacola. Estava sendo apoiado perlos demais policcias. Foi na abordagem. Ele tentou se desvenchilhar mas o depoente se identificou e o conteve. Ele não teve acesso ao portão que dá acesso a uma vila. Com ele encontrou uma sacola com entorpecente e dinheiro. havia crack, cocaína, maconhe. Nessa bolsa não se recorda se havia lança perfume. Havia dinheiro com ele, cerca de 200 reais. Na lateral desse, próximo a uma caixa d'água. Ele indicou que dentro da viela tinha mais. Acabou encontrando o restante da droga no local indicado. Não o questionou apos o encontro da droga essa droga era do acusado. Trabalha no 87 DP. A caixa de água é azul. As pessoas do trafico correram. Nunca havia visto o réu antes dos fatos.

O policial Rogério declarou que foi no apoio de Eduardo e Rodolfo. Apenas auxiliou

a conduzir o réu a unidade policial. Não conversou com o réu. Não assinou o documento, não leu o depoimento.

Como se vê, o quadro probatório é sólido e não frágil como aduziu a defesa. Não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do acusado. Os elementos de convicção colhidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

Os policiais não tinham motivo algum para acusar injustamente o acusado e seria um absurdo que eles estivessem na posse do entorpecente e dinheiro apreendido, demonstrado a fls. 29, no intuito de prejudicar um trabalhador inocente.

independentemente da alegação da parte, mas em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas em depoimentos prestados por policiais, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em alguns policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social.

A suspeita decorre do comportamento apurado no processo e não da mera condição destas pessoas, até porque não existe no Ordenamento Jurídico Pátrio qualquer restrição em relação à validade de depoimentos de policiais além do que não está provada, cientificamente, qualquer tendência destas pessoas faltarem com a verdade. Refutar a validade de um depoimento, baseando-se apenas na qualidade ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado.

Mas não é só.

É sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuísse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel.Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel.Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido ainda:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.

Doutrina e jurisprudência” (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96).

O réu negou os fatos.

Fabrizio declarou que tem vinte e cinco anos de idade. É padeiro mas estava trabalhando com o padraço na feira, menos de 2as e 6as. Não está recebendo visitas no presídio. O padraço é autônomo. Mora com a mãe, o padraço, e o filho. Nesse dia estava de folga, estava na casa da namorada. Ela ouviu um barulho em cima do telhado e ficou assustada. Foi ver o que estava ocorrendo e nisso alguns segundos depois viu uma pessoa passando com a moto. Ficou olhando. Era um dos policiais. O policial já mandou "mão pra cabeça". Nisso ele perguntou do Ônix prata e disse que nada sabia. Estava almoçando na casa da namorada que estava presente e saiu na hora

que o viu falando. Ela viu o momento que foi preso. Não estava com droga alguma. Estava deitado no chão e depois de vasculharem a viela, encontraram uma sacola preta na laje. A parte debaixo da casa da namorada é uma garagem. A casa é verde do portão branco. A casa tem três andares. Ela morava com o cunhado conhecido por "paraíba" e a irmã.

A versão do acusado é completamente despropositada.

Com efeito, não há prova alguma de que o réu estivesse na casa de sua namorada, pessoa que sequer compareceu em juízo para comprovar que reside no número 53 da rua onde ele foi preso.

Assim, não há justificativa plausível para que ele estivesse naquele local que não a pratica do crime em questão.

Aliás o réu não comprovou trabalho lícito e está sendo processado por outro tráfico de entorpecentes junto a 3ª Vara Criminal Central, autos número 1506465-

14.2021.8.26.0228 do qual, aliás, já consta sentença condenatória em primeiro grau. Sua versão fantasiosa não é capaz, nem de longe, de infirmar as palavras dos policiais os quais focaram categóricos quanto a prática ilícita por parte do acusado.

Daí porque, confrontados os elementos de prova, afigura-se de rigor a condenação. Passo a dosar a pena:

Fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Isto porque, a meu sentir, não há razões para que a pena base seja aumentada além do mínimo já que os tipos de entorpecente apreendidos em posse dele bem como a quantidade, não desbordam do que ordinariamente já está previsto no tipo penal. Portanto, quanto a este aspecto, discordo da posição trazida pelo Ministério Público.

Em segunda fase, nada a ser reconhecido.

Em terceira fase, pesem as ponderações trazidas pelo Ministério Público, entendo que é o caso de aplicação do tráfico privilegiado, ou seja, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. O réu é tecnicamente primário e não possui Maus Antecedentes, fls.107/108. Não se pode presumir, de outra banda, que ele se dedicava à atividade criminosa de forma habitual ou, ainda, que integrasse organização criminosa sem uma base probatória que assim autorize essa presunção. Só é viável o afastamento da benesse se a condição de reincidente ou portador de Maus Antecedentes, bem como de integrante de organização criminosa ou delinquente habitual, restarem devidamente comprovadas. Não basta que tenha sido preso em flagrante por tráfico na posse de variados tipo de entorpecente para se atribuir ao réu a prática de atividades criminosas que impeçam a redução da pena. E o fato dele não comprovar trabalho lícito, a meu ver, não é suficiente a comprovar essa situação. É necessário que dos autos, ou das circunstâncias da prisão, sobressaiam elementos indicativos de outras atividades ilícitas que não o próprio tráfico em si. Contudo, a carga redutora a ser aplicada, nos termos do artigo 42 da Lei de Entorpecente é a de 1/4. Isto porque o acusado estava com razoável quantidade de substância entorpecente, inclusive de alto poder viciante, no caso 213,24g de cocaína e 26, 5g de crack. Daí porque não pode ser brindado com o redutor em sua carga máxima ou mesmo no equivalente a metade. O crime é gravíssimo e deve ter tratamento rígido.

Assim sendo, diminuo a pena anteriormente aplicada em 1/4 (um quarto), com o que a reprimenda privativa de liberdade resulta em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida.

Por fim, estabeleço o regime aberto para cumprimento da reprimenda. De fato, o réu é tecnicamente primário, não ostenta antecedentes e a quantidade de pena autoriza a fixação de regime aberto. Além do que, apesar de o art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90 determinar a fixação de regime inicial fechado para cumprimento do delito de tráfico de entorpecentes, por equipará-lo a hediondo, esta previsão não se aplica ao tráfico privilegiado. Como cediço, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que o delito de tráfico de drogas,

quando há o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não é equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90, conforme se depreende do teor da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida” (Habeas Corpus nº 118.533/MS - Tribunal Pleno- Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 23.06.2016).

No mesmo sentido, os recentes Habeas Corpus nº 136.545, de relatoria do Min. Celso de Mello, j. 07.10.2016; nº 136.762, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.10.2016; e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 937.651, de relatoria do Min. Roberto Barroso, j. 09.09.2016.

Consequentemente, concedo o apelo em liberdade.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno FABRICIO GRACIANO SILVA ARAUJO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, “caput” e § 4º da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, calculados no mínimo legal, e corrigidos desde a data do fato. Outrossim, não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho meu entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão.

Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, até porque a conversão das penas privativas de liberdade não é automática, devendo o Magistrado analisar os preceitos estabelecidos do Código Penal.

No presente caso, temos que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu, que claramente praticava o comércio de drogas é insuficiente para a prevenção e repressão do delito, sendo, portanto, sua concessão, vedada pelo art. 44, inciso III, e 77, II, ambos do Código Penal.

O réu praticou crime gravíssimo, sendo com ele apreendido drogas de alto potencial lesivo, droga esta capaz de atingir a um sem-número de usuários e viciados. Assim, pelas circunstâncias concretas do crime, não há indicação de que tal substituição ou seja suficiente ou recomendável.

Cumram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, “d”, do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Decreto o perdimento do valor apreendido (fls. 20/21). Encaminhe-se ofício ao SENAD, comunicando acerca desta decisão e indicando a declaração de perdimento para os fins de sua destinação, ex vi do constante no art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/06; Transitada esta em julgado tornem conclusos para a designação de data para

audiência admonitória.
Expeça-se Alvará de Soltura Clausulado.
Isento de custas.
Publicada em audiência.

São Paulo, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA